

1500204-03.2020.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2162753/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 12244417 - DEL.SEC.ANDRADINA, 702/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500204-03.2020.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-03.2020.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2162753/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 12244417 - DEL.SEC.ANDRADINA, 702/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2162753 - DISE - DEL.SEC.ANDRADINA, 702/20/100 - DISE - DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULA RITA DE CASSIA SOUZA e outro

O Ministério Público ofereceu denúncia contra PAULA RITA DE CASSIA SOUZA e RAFAEL CANDIDO PEROZINI imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 29, caput, do Código Penal).

Narra a denúncia que no dia 04 de julho de 2020, por volta das 20 horas e 15 minutos, na Rua Isabel Santos Knecht, nº 235, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e Comarca de Andradina, os réus, vulgo "Rafinha", qualificados às fls. 06 e 94/95, respectivamente, previamente ajustados e conluiados, um aderindo à conduta do outro, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 07 (sete) porções da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, pesando aproximadamente 70,53g, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2020, em fls.118/121. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.161/162.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação,

entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa da acusada Paula Rita, por sua vez, requereu a absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas de comércio (CPP 386, V e VII) e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta (crime do art. 28), aplicação da atenuante da confissão, e do redutor do § 4º; a d. Defesa do acusado Rafael, a seu turno, requereu a absolvição por falta de provas da vinculação da droga com o réu. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF em fls.01/02, termo de depoimento em fls.03/05, termo de interrogatório em fl.06, boletim de ocorrência de fls.14/16, autos de exibição e apreensão de fls.17, fotografias em fls.21/23, laudos periciais de fls.101/103 e 207/209), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Magno Inácio Ramos e Cristiano Fernandes Coutinho, policiais, confirmaram que receberam informação anônima de que o acusado Rafael, que fora preso por tráfico dias antes, mas solto em audiência de custódia, estaria novamente praticando o delito, desta vez utilizando-se uma casa vizinha à sua para guarda de drogas.

Então, deslocaram-se para o local e depararam-se com a acusada Paula em frente à casa, a qual franqueou a entrada dos policiais. Após buscas, Paula mostrou-se bastante emocionada quando os policiais entraram na cozinha; então, localizaram pedras de crack no fogão e mais uma pedra em um quarto da casa, além de balança de precisão. Paula disse que estava guardando as drogas para o réu Rafael. Paula não era conhecida como traficante e, sim, como mera usuária de drogas.

Interrogada, Paula confirmou a versão dos policiais, dizendo que naquele dia mesmo Rafael havia pedido que guardasse drogas para ele, ao passo em que respondeu a ele afirmativamente, mas condicionando tal fato à entrega de um "raio" de cocaína em contrapartida. Rafael era seu vizinho há poucas semanas. Não sabia a quantidade que Rafael esconderia na sua casa, nem que havia balança de precisão.

Interrogado, o réu Rafael negou os fatos. Disse ser perseguido pela polícia em razão de seu passado, de anterior prática de tráfico, sendo que já chegou inclusive a ficar internado na Fundação Casa. Sobre os fatos, disse que os vizinhos ao lado de sua casa faziam barulho durante a madrugada e que reclamou; por isso, sofreu represálias, daí a razão de terem indicado que seria traficante.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese houve a apreensão de cerca de 70 gramas de crack, quantidade deveras relevante, além de uma balança de precisão. Apenas a título de argumentação, anote-se que a pedra de crack para consumo imediato tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). É dizer: os 70 gramas apreendidos seriam suficientes para até 350 "cachimbos" de crack.

Quanto ao local e circunstâncias da ação, os policiais narraram que receberam informação de que o réu Rafael continuaria a praticar tráfico, pois havia sido preso recentemente - dias antes - pelo mesmo crime, sendo solto após audiência de custódia, e que desta vez usaria uma casa ao lado da sua para guardar a droga.

Na diligência, a acusada Paula permitiu o ingresso da polícia no local, sendo que os agentes públicos encontraram as drogas e a balança de precisão. Paula, então, teria dito que guardava a droga para Rafael, o qual lhe daria uma porção ("um

raio") de cocaína por ter guardado a droga para ela.

Nota-se que a ida dos policiais ao local foi direcionada: receberam informação específica a respeito da possível renitência de Rafael em praticar o crime de tráfico o que culminou com a apreensão das drogas em residência vizinha, à época dos fatos, à do réu.

A acusada Paula, em seu interrogatório, confirmou os fatos assim como narrados na denúncia. Relatou, de forma detalhada e consistente, que Rafael lhe pediu para guardar drogas na sua casa e que disse para ele "depois você me dá um raio (de cocaína) então". Adicionou que não sabia a quantidade de drogas que o réu guardaria ali - se soubesse que a quantidade era aquela, não teria permitido, porque residia com seus filhos. Apontou, ainda, que pouco tempo depois, no mesmo dia, a polícia chegou e a surpreendeu com as drogas. Disse ter medo de Rafael.

Rafael trouxe versão bastante insólita, de que estaria sendo acusado por perseguição dos policiais e por ter se desentendido com os vizinhos, os quais costumavam ouvir música madrugada adentro e fazer muito barulho. Como reclamou de tal perturbação, estaria sofrendo represálias.

Entretanto, a análise dos antecedentes de Rafael (conforme determina o supra citado art. 28, § 2º), denota seu envolvimento com atividades criminosas pretéritas: já foi condenado definitivamente por crime de porte de arma, e já foi preso em outras circunstâncias relacionadas a drogas, sendo que, conforme seu interrogatório, já foi internado na Fundação Casa também por tráfico.

Em suma, as provas dos autos conduzem à conclusão de que a versão dos policiais e da acusada Paula é verdadeira. Adicione-se o fato de os policiais terem dito que Paula era conhecida como usuária de drogas, e Rafael como traficante. Tudo a confirmar a versão acusatória, não infirmada pelo acusado. Ao contrário do quanto preconizado por sua defesa, há provas suficientes de sua vinculação com as drogas, seja pela informação recebida pelos policiais, seja pelo fato de estar em uma residência vizinha à sua, tendo a moradora do local confirmado que guardaria a droga para o acusado.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015). Assim, a conduta de ambos os acusados enquadra-se no tipo em questão.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico é procedente, em relação a ambos os réus.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados

pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais”. E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base”.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

1 - Rafael Cândido Perozini

Na primeira fase, a natureza (crack, a droga que mais causa danos à saúde no país) e quantidade (suficiente para 350 doses individuais, patamar elevado para os padrões da Comarca de cerca de 55 mil habitantes) recomendam a exasperação da pena-base em 1/8, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito). Nesse passo, estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Além disso, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (fl. 234 - crime de porte ilegal de arma de fogo cometido em 15/04/2020), já que cometeu crime anterior ao fato deste processo, cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.”

Assim, exaspero a pena-base em mais 1/8, pelo mesmo critério de cálculo.

A pena fica então em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 por conta dos antecedentes criminais do acusado.

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e antecedentes deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

2 - Paula Rita de Cássia Souza

Na primeira fase, assim como para o acusado Rafael, exaspero a pena-base em 1/8, a estabelecendo em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, ante a confissão, atenuo a pena, que retorna ao mínimo legal.

Cabível a aplicação do redutor, pois aparentemente a prática do crime se deu de forma episódica, sem vinculação a organizações criminosas. Assim, a pena fica em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Excepcionalmente, cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em pagamento de um salário mínimo, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução.

Caso haja descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, considerando-se as circunstâncias judiciais negativas em cotejo com a primariedade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às seguintes penas:

1) PAULA RITA DE CÁSSIA SOUZA: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial semiaberto. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em pagamento de um salário mínimo, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução. Autorizo o parcelamento, em até 10 parcelas.

2) RAFAEL CANDIDO PEROZINI à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. Não vislumbro razões para a decretação da prisão preventiva do acusado Rafael, notadamente tendo em vista o CPP 315, § 1º.

Condeno os réus ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 26 de janeiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)